

1500146-16.2020.8.26.0535

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: NAIRA BLANCO MACHADO

Comarca: Arujá

Foro: Foro de Arujá

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 31/08/2022

... para a condenação dos réus pelo delito de tráfico de drogas, mas quanto ao delito de associação para fins de tráfico devem os acusados serem absolvidos, ante ausência de provas de tal delito. Na dosimetria, quanto à ré, na terceira fase pode ser beneficiada, dada a primariedade, pelo reconhecimento do tráfico privilegiado, não havendo o que ser considerado em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Arujá

Foro de Arujá

1ª Vara

Avenida Albino Rodrigues Neves, 394, Aruja - SP - cep 07400-000

1500146-16.2020.8.26.0535 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500146-16.2020.8.26.0535

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEANDRO CESAR CARDOSO e outro

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). NAIRA BLANCO MACHADO

Vistos.

LEANDRO CESAR CARDOSO e MARIA DO SOCORRO CABRAL BELO, qualificados no autos, foram denunciados pela prática do crime descrito no art. 33, caput, c/c art. 35, ambos da Lei 11.343/06, porque no 17 de janeiro de 2020, por volta das 01:00 horas, na Rua Três, 580, Parque Rodrigo Barreto, nesta cidade de Arujá, atuando em concurso de agentes, traziam com eles, sem autorização e em desacordo com determinação legal, para fins de entrega a terceiros, 101 eppendorfs de cocaína, (11,3 g massa líquida), 191 eppendorfs de cocaína (35,2 g, massa líquida) e 40 porções de maconha (44,2 g massa líquida), drogas essas que causam dependência física e psíquica. Ainda, em data incerta e até a data acima indicada, os acusados associaram-se entre si para praticarem delito de tráfico de drogas.

Narra a acusação que policiais estavam em patrulhamento de rotina no local dos fatos quando suspeitaram do acusados, que apresentaram nervosismo ao perceberem a viatura da polícia. Os acusados foram abordados, e a acusada Maria estava trazendo numa bolsa azul 191 eppendorfs de cocaína e 40 porções de maconha, além de um celular. O acusado Leandro trazia numa sacola 101 eppendorfs de cocaína e R\$ 102,00 em dinheiro. Leandro admitiu aos policiais que estava vendendo drogas no local, enquanto a acusada Maria confirmou estar abastecendo ponto de tráfico, dizendo que pegou a droga com "Bia" e receberia R\$ 20,00 para levar a droga até "a loja". Auto de Prisão em Flagrante Delito às fls. 01/02. Boletim de Ocorrência às fls. 08/11. Auto de Exibição e Apreensão às fls. 12/13. Laudo de constatação de

substância entorpecente às fls. 17/19. Laudo pericial definitivo às fls. 150/152 e 173/175. Laudos periciais às fls. 168/172.

Em audiência de custódia (fls. 61/65) a prisão em flagrante foi convertida em preventiva.

A decisão de fls. 99/102 concedeu a liberdade provisória aos acusados, em 30/01/2020, impondo medidas cautelares diversas da prisão, sendo cumpridos os alvarás de soltura em 03/02/2020 (fls. 133 e 154).

Notificados, os réus apresentaram defesa preliminar às fls. 194/197 e 231/232.

A denúncia foi recebida em 23/02/2021 (fls. 239/240).

Em audiência foram ouvidas testemunhas e interrogados os acusados (fls. 307/311). O Ministério Público, em alegações finais orais, pugnou pela parcial procedência da denúncia. Aduziu que há provas suficientes para a condenação dos réus pelo delito de tráfico de drogas, mas quanto ao delito de associação para fins de tráfico devem os acusados serem absolvidos, ante ausência de provas de tal delito. Na dosimetria, quanto à ré, na terceira fase pode ser beneficiada, dada a primariedade, pelo reconhecimento do tráfico privilegiado, não havendo o que ser considerado em primeira e segundas fases de dosimetria. Quanto ao corréu, aduziu que não há o que ser considerado em primeira e segunda fases de dosimetria, mas em terceira fase o réu não faz jus ao tráfico privilegiado, uma vez que há três processos de tráfico em face do réu em 2020. Afirmou que o réu respondeu por furto na capital, suspenso pelo art. 366, do CPP. Aduziu que o réu é tecnicamente primário, mas isso cede diante de tantos crimes que ele responde. Pugnou pelo regime fechado ao réu Leandro, pois somente preso teria cessado sua conduta delituosa.

Em alegações finais orais, a defesa da ré Maria do Socorro requereu que seja a ré absolvida pelo delito de associação ao tráfico, por ausente provas de tal crime. Em relação ao delito de tráfico, sustentou que devem ser levadas as condições pessoais da acusada quando se verifica sua versão dos fatos (pobre, baixa renda e pouco estudo). Afirmou que a acusação deve provar o dolo específico e que a ré sabia o que continha a bolsa. Assim, pugnou pela absolvição da ré por falta de provas. Afirmou que a ré poderia ser vista como mula para levar a droga para determinado local, sem contudo saber que transportava tal entorpecente. Subsidiariamente, requereu o reconhecimento de tráfico privilegiado, com redução ao máximo e fixação de regime aberto, até mesmo com a substituição por restritiva de direitos.

A defesa do réu Leandro, em alegações finais de fls. 324/327 requereu a absolvição do acusado dos delitos. Alegou que inexistem provas de cometimento do delito pelo réu.

Vieram-me conclusos os autos para sentenciamento.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Os autos estão em ordem. Não há preliminar a ser apreciada ou nulidade a ser declarada. Logo, o feito está apto a ser julgado.

A pretensão punitiva estatal penal é parcialmente procedente.

A materialidade do delito de tráfico está demonstrada pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante delito, laudo de constatação da substância entorpecente, laudos periciais e prova oral produzida.

A autoria dos réus pelo delito de tráfico segue a mesma sorte.

Não se comprovou, ademais, a materialidade e autoria do delito de associação para fins de tráfico.

Passo à análise da prova oral colhida no feito.

A testemunha Marcus Vinicius Camargo declarou ser policial militar e disse que foi ele e seu parceiro que realizaram a prisão. Estavam em patrulhamento e ao adentrar em local conhecido como ponto de venda de drogas, viram os réus, que não correram. Com eles havia a quantidade de drogas. Havia drogas na bolsa da ré e o réu tinha uma sacola com drogas e dinheiro. Afirmou que havia muita droga separada para a venda. Maria disse que ia abastecer ponto de venda de drogas.

A testemunha Ednaldo Barbosa declarou que se recorda que em patrulhamento avistaram os réus em local de ponto de venda de drogas. Abordaram os acusados e Leandro tinha 101 pinos de cocaína e R\$ 102,00. A ré trazia uma bolsa azul e bege e com ela havia na 40 invólucros de maconha e 191 pinos de cocaína, além de um celular. Conversaram

com eles separadamente. O réu confessou a venda e a ré disse que abastecia o comércio de entorpecentes e ganharia R\$ 20,00 por tal prática. Disse que nesse local sempre mudam as pessoas que vendem drogas. Eles não falaram há quanto tempo faziam isso, só confessando os fatos daquele momento, de venda por Leandro e abastecimento pela ré.

A ré Maria do Socorro Cabral Belo declarou em interrogatório judicial que tem 25 anos, é babá, não é registrada e recebe R\$ 650,00. Estudou até o segundo ano do segundo grau. É solteira e sem filhos. Nunca foi processada antes. Disse que referente aos fatos, não é associada ao tráfico, e no dia dos fatos até então encontrou sua amiga Bia e ela falou que como estava indo na direção, perguntou se ela podia levar a bolsa. Achou estranho e precisava de dinheiro. Ficou cismada e ela falou “do nada”, que se ela ia na direção, poderia levar a bolsa que não era nada para prejudicar. Foi levando a bolsa tranquilamente e não sabia o que tinha dentro. Foi abordada pelos policiais que viram o que tinha dentro. Afirmou que Bia ia lhe dar R\$ 20,00 para ela poder pagar uma conta. Estava “apertada” e desesperada por ter saído do serviço. Não conhecia o Leandro. Disse que quando a menina lhe deu a bolsa não especificou o que tinha dentro e ela falou que um rapaz estava esperado pela bolsa, sendo então abordada. Ela não falou o nome, nem especificou como ele era, o rapaz que iria até ela pegar a bolsa. Não sabia o que tinha dentro, mas achou suspeito. Mesmo achando suspeito fez isso por precisar do dinheiro.

O réu Leandro Cesar Cardoso declarou em interrogatório judicial que tem 31 anos e era motorista de caminhão. Disse que sofreu um acidente quando trabalhava como ajudante geral e estava movendo ação trabalhista. Sofreu lesões na coluna e tem dificuldades em se mover. Afirmou que estudou até o segundo grau completo. É casado e tem enteada, além de sua mãe. Afirmou que está preso por outra suspeita de tráfico de drogas. Disse que além desses dois processos não tem outro processo. Quanto aos fatos, disse que no dia dos fatos estava saindo de casa e é usuário de drogas. Tem dependência química desde os 15 anos. Já foi internado e fez acompanhamento pelo caps, o que pode ser comprovado por laudo. Tinha um dinheiro e foi ao ponto de venda de drogas na rua 03 e não tinha ninguém. Retornou à rua 4, comprou bebida na adega e subiu para a rua 03, pois queria ir para a avenida Armando Colângelo por uma viela. Na viela encontrou os policiais que o abordaram. Foi achado com ele R\$ 5,00, a bebida, e um cachimbo e isqueiro. Foi levado para a rua 03 e no local lhe bateram, perguntaram onde estava a droga e não sabia, pois não havia ninguém no ponto de venda de drogas. Nesse momento apareceu a corré com uma sacola e o policial desconfiou dela, mandou que ela retornasse. Ela disse que procurava uma pessoa e morava na rua 04. Ela disse que nada havia na bolsa. Afirmou que na bolsa dela havia drogas e dinheiro. Quer deixar claro que sofre de epilepsia, esquizofrenia e tem essa lesão na medula. Toma cinco tipos de remédio controlado (gardenal, tramal e mais três medicamentos). Disse que é impossível que tenha feito isso, pois se pudesse traficar, iria trabalhar. Sempre trabalhou na sua vida. É só ele e sua mãe, não quer perder sua família por conta dessa iniciativa dos policiais. Os policiais já o abordaram fazendo uso de drogas. Disse que não conhecia a corré.

Essa foi a prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

De início, impõe-se absolver os réus no tocante ao crime de associação para o tráfico, conforme requereu o próprio Órgão Ministerial em sede de alegações finais. Isto porque, não restou devidamente demonstrado no caso em tela a prática do delito de associação para o tráfico, eis que os elementos probatórios são insuficientes à certeza de sua ocorrência.

Como é cediço, o crime do art. 35 da lei 11.343/2006 é uma espécie de quadrilha ou bando específico do tráfico ilícito de entorpecentes, exigindo para a sua configuração a comprovação de sua permanência. Afirma Guilherme de Souza Nucci (2009, p.365):

“Demanda-se prova de estabilidade e permanência da mencionada associação criminosa.” E mais: “exige-se elemento subjetivo do tipo específico, consistente no animo de associação, de caráter duradouro e estável. Do contrário, seria um mero concurso de agentes para a prática de crime de tráfico.”

No caso em testilha, não tendo sido comprovado o caráter de estabilidade e permanência da associação, não há como se imputar aos acusados a prática do crime em questão, não tendo, desta feita, se desincumbido o Ministério Público do ônus probandi que lhe é imposto.

No mesmo sentido, manifesta-se a jurisprudência, inclusive a do Superior Tribunal de Justiça:

Para a configuração do delito de associação para o tráfico de drogas, é necessário o dolo de se associar com estabilidade e permanência, sendo que a reunião de duas ou mais pessoas sem o animus associativo não se subsume ao tipo do art. 35 da Lei n. 11.343.2006". (HC 349837/SP, 5ª Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, v.u., j. 03.05.2016. No mesmo sentido REsp 1501842/PR, 6ª Turma, rel. Min. Rogério Schietti Cruz, v.u., j. 05.04.2016).

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - DENÚNCIAS ANÔNIMAS QUE APONTAVAM NOMINALMENTE AS PESSOAS DOS RÉUS COMO TRAFICANTES - APREENSÃO DA DROGA EM LOCAL PRÓXIMO - ELEVADA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES - DEPOIMENTO DE POLICIAIS - VALIDADE - TESES DEFENSIVAS NÃO COMPROVADAS - AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS - RECURSO MINISTERIAL - ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - AUSÊNCIA DE PROVA DA ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DO VÍNCULO ASSOCIATIVO - MANUTENÇÃO - APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º, DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06 - POSSIBILIDADE. - Aos depoimentos prestados por policiais deve-se dar crédito como se de qualquer outra testemunha fossem, eis que prestam compromisso e estão sujeitos às penalidades legais pelo falso, mostrando-se hábeis, portanto, a confirmar os fatos expostos no flagrante e comprovar a autoria delituosa. - Tendo os policiais recebido denúncia anônima apontando as pessoas dos réus como traficantes, e sendo eles abordados em lugar conhecido como ponto de venda de drogas, apreendida em local próximo elevada quantidade de entorpecentes, deve ser mantida a condenação. - Para caracterização do crime do art. 35, da Lei nº 11.343/06, deve ser comprovada a estabilidade e permanência do vínculo associativo, não demonstradas no presente caso, mantendo-se a absolvição declarada na sentença. (TJ-MG - APR: 10079073229183001 MG, Relator: Delmival de Almeida Campos, Data de Julgamento: 15/05/2013, Câmaras Criminais / 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 22/05/2013, undefined)

Como mencionado alhures, mesmo que entendêssemos estarmos diante de alguns indícios de associação, isso não deve bastar para caracterizar a culpabilidade dos réus pelo delito em questão, especialmente quando toda a investigação não veio acompanhada de uma apuração mais rigorosa destas circunstâncias.

No caso, pode-se até cogitar de probabilidade do crime de associação, mas o fato é que, "no processo criminal, máxime para condenar, tudo deve ser claro como a luz, certo como a evidência, positivo como qualquer expressão algébrica. Condenação exige certeza absoluta, fundada em dados indiscutíveis, de caráter geral, que evidenciem o delito e a autoria, não bastando a alta probabilidade desta ou daquele. E não pode, portanto, ser a certeza subjetiva, formada na consciência do julgador, sob pena de transformar o princípio do livre convencimento em arbítrio." (RT 619/267).

Outrossim, para configuração do delito de associação não se exige que os componentes da associação se conheçam e que haja nítida divisão de funções. Basta, apenas, que a associação vise à prática de um número incerto de crime, por tempo indeterminado (elemento subjetivo do tipo). No caso dos autos, todavia, a presença de vínculo estável e psicológico entre os agentes não restou evidenciada pelas provas produzidas.

Registre-se que não houve investigação prévia sobre a atuação dos acusados ou mesmo posterior que pudesse confirmar o vínculo associativo descrito na exordial acusatória. Ademais, os próprios réus, à sua maneira, negaram a associação, dizendo que mal se conheciam.

Ainda, não foram encontrados com os acusados anotações, balança ou outros insumos

que pudessem revelar ou confirmar uma ligação estável e permanente entre eles para prática reiterada de crimes, nem mesmo de tráfico.

No tocante ao crime de tráfico o desfecho dos autos é outro.

Os policiais ouvidos em juízo informaram como ocorreu a prisão dos réus e o encontro das drogas, alegando que o réu Leandro trazia com ele 101 eppendorfs de cocaína e R\$ 102,00. A ré, conforme narraram os policiais, tinha em seu poder 191 eppendorfs de cocaína, 40 porções de maconha e um celular, o que estavam numa sacola azul e bege. Segundo os policiais, na hora da abordagem a ré confirmou que abastecia pontos de tráfico com a droga e o réu confirmou que vendia entorpecentes. Os acusados, por seu turno, negaram o cometimento de tráfico. A ré Maria confirmou em interrogatório judicial que trazia a sacola, mas disse que pessoa de nome Bia pediu que ela fosse a um local, um homem a veria e pegaria a sacola.

Já Leandro afirmou que não tinha drogas em seu poder, alegou ser usuário de entorpecentes e ter muitos problemas de saúde. Afirmou que se tivesse condições de traficar, estaria trabalhando, tendo sofrido acidente em trabalho. Alegou que policiais agiram com violência e nega ter confirmado aos policiais que realizava o tráfico. Ambos acusados disseram que não se conheciam.

Os réus, em solo policial, permaneceram em silêncio (fls. 06/07).

Vê-se que o exame toxicológico confirmou a natureza entorpecente das drogas localizadas (fls. 150/152 e 173/175).

Pois bem.

Nota-se que ante a prova existente nos autos o réus devem ser condenados pelo delito de tráfico de drogas.

Cabe observar que embora o réu Leandro tenha negado a propriedade da droga, afirmando que tinha saído para adquirir drogas para seu uso próprio, e após não encontrar ninguém vendendo drogas em determinado lugar, comprou uma bebida e passou a andar pelo bairro, em direção a outro ponto de venda de drogas, até que veio a ser abordado, sua versão não é digna de credibilidade.

Saliente-se que os próprios policiais afirmaram que o local é bem conhecido como ponto de venda de drogas.

E é importante salientar que em delitos de tráfico de drogas, cometidos, normalmente, na clandestinidade, a prova, em regra, é composta por depoimentos dos policiais, que de modo geral, são suficientes a demonstrar a culpabilidade de um réu, desde que em consonância com as demais provas carreadas aos autos, como ocorre no caso em tela, visto que a tese defensiva não se revelou robusta o suficiente para contrapor a tese acusatória.

Insta observar que apesar de o réu afirmar que é usuário de drogas, justificando a sua abordagem no local dos fatos e o encontro das drogas em seu poder pelos policiais, afirmando que seria impossível estar traficando pois se tivesse condições físicas iria estar trabalhando e não praticando o comércio espúrio, seu relato não convence.

E no caso dos autos, o conjunto probatório é robusto e idôneo para o reconhecimento da culpabilidade do réu Leandro, porque ao lado dos depoimentos policiais, há a apreensão do entorpecente onde estava o acusado, circunstância que não foi por este negada.

Insta destacar que é de conhecimento deste Juízo que o réu responde a outros dois processos criminais por tráfico de drogas, 1502552-12.2020.8.26.0045 (no qual foi absolvido), e nos autos 1501107-54.2020.8.26.0045

Ocorre que, o que se observa é que os relatos do réu, prestados nos três autos, são muito semelhantes, sempre buscando se isentar de responsabilidade pelo exercício da traficância, alegando ser usuário e que por ser acometido de moléstias físicas não corre quando chega a polícia ao local e termina sendo abordado.

Entretanto, as circunstâncias da prisão do réu nos três feitos termina, na verdade, por evidenciar a sua culpabilidade, tornando-se deveras dificultoso crer que o réu tenha sido abordado pelos policiais atuantes na Comarca, em três oportunidades diferentes, em locais comumente conhecidos como pontos de tráfico de drogas, sem que tenha algum envolvimento com o comércio espúrio.

Não se olvida que é no ponto de venda drogas que um usuário costumeiramente se dirige a fim de comprá-las para seu consumo, o que a princípio justificaria a

presença do réu nos locais das abordagens.

Todavia, as repetidas apreensões do réu, sob circunstâncias muito semelhantes, sendo sempre afirmado pelos policiais ouvidos que traz consigo uma sacola contendo entorpecentes, somadas ao fato de que no caso particular dos autos foi apreendido em seu poder razoável quantidade de drogas e dinheiro (101 eppendorfs de cocaína com 11,3 g massa líquida e R\$ 102,00 em dinheiro), não sendo possível admitir que estariam em seu poder apenas para consumo próprio, culminam na inarredável condenação.

Ressalte-se que nos autos 1501107-54.2020.8.26.0535, segundo consta, o réu foi apreendido portando 19 eppendorfs de cocaína e R\$ 238,00 em dinheiro. Somando-se à quantia dos autos, totalizam 120 eppendorfs e R\$ 340,00 em dinheiro, num curto período de tempo, cerca de quatro meses, quantia essa que não se coaduna com a alegação de aquisição das drogas para consumo próprio.

Quanto á ré Maria do Socorro, tem-se que não negou que trazia a bolsa na qual continha drogas, alegando, contudo, que não tinha conhecimento do que havia no interior da bolsa, mas que ficou "cismada". Disse que acabou aceitando entregar a bolsa por precisar do dinheiro (R\$ 20,00).

Nota-se que a acusada Maria do Socorro agiu com dolo, não podendo ser acolhida a tese da defesa de que inexistente conduta ilícita por desconhecer a ré o conteúdo da bolsa. Vê-se que a versão da acusada de que não sabia que transportava maconha e cocaína não se mostra crível, não tendo trazido a acusada qualquer elemento de prova passível de gerar alguma dúvida no tocante a sua culpabilidade, e com isso, ensejar a aplicação do princípio in dubio pro reo.

A acusada agiu, no mínimo, com dolo eventual, uma vez que ela confirmou que poderia haver algo suspeito na bolsa..

Neste sentido:

Apelação. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Preliminar. Alegação de inépcia da denúncia. Mérito. Pedido de absolvição por insuficiência probatória. Pleitos subsidiários: a) redução do aumento operado na primeira fase; b) aplicação do redutor previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, no patamar máximo. 1. Alegação de inépcia da denúncia. Não acolhimento. Denúncia suficientemente detalhada com descrição pormenorizada das condutas atribuídas aos réus. Indicação do objeto material do tráfico e das circunstâncias de tempo e local. 2. Associação para o tráfico de drogas. Delito não comprovado. Estabilidade e permanência que não se inferem dos elementos coligidos aos autos. Absolvição que se impõe. 3. Tráfico de drogas. 3.1. Prova da materialidade e de autoria. Depoimentos dos policiais uniformes e convergentes ao longo da persecução penal. Presença de contradições nas versões apresentadas pelos réus, enfraquecendo-os de credibilidade. Conduta dirigida ao comércio espúrio. 3.2. Alegação de desconhecimento quanto ao conteúdo do porta-malas do veículo que conduziam. Versão fantasiosa dos réus que não se sustenta. Apreensão de vultosa quantidade de entorpecente que não poderia passar despercebida. 4. Dosimetria da pena que comporta reparos. 4.1. Aumento desproporcional da pena base. Quantidade de droga excessiva apreendida com os réus. Aumento em razão de uma única circunstância judicial desfavorável. Readequação do aumento operado para o dobro acima do mínimo legal. 4.2. Aplicação da fração e 1/6 (um) sexto em razão do reconhecimento da reincidência do réu Jackson. 5. Do regime inicial para o cumprimento da pena. Fixação do regime fechado. Circunstâncias judiciais desfavoráveis que permitem a fixação do regime inicial mais rigoroso. 6. Recursos conhecidos e parcialmente providos. (TJSP; Apelação Criminal 1526141-16.2019.8.26.0228; Relator (a): Marcos Alexandre Coelho Zilli; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 13ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 15/06/2021; Data de Registro: 16/06/2021) (grifos nossos)

Recorda-se, ainda, que o crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06 é de ação múltipla, de modo que se consuma com qualquer das outras condutas descritas no mencionado dispositivo legal, como, transportar, trazer consigo, guardar, ter em depósito, entregar a consumo e fornecer drogas, ainda que gratuitamente. Nesse sentido:

"HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. TESES DE QUE A PROVA OBTIDA NOS AUTOS É ILÍCITA, E DE QUE O CRIME É IMPOSSÍVEL, POR NÃO TER CHEGADO AO DESTINO, QUE NÃO FORAM VENTILADAS NAS RAZÕES RECURSAIS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDUTA DE TRANSPORTAR OU TRAZER CONSIGO, COM O INTUITO DE FORNECER, AINDA QUE PARA GRATUITO CONSUMO ALHEIO, QUE SE SUBSUME AO TIPO PREVISTO NO CAPUT DO ART. 33, DA LEI N.º 11.343/06. CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA E CONTEÚDO VARIADO. CONSUMAÇÃO. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADO. [...] 2. "Transportar", "trazer consigo" ou "fornecer ainda que gratuitamente" substância entorpecente ilícita são São Paulo núcleos do tipo do delito de tráfico de drogas - crime de perigo abstrato, de ação múltipla e conteúdo variado, que se consuma com a prática de quaisquer das ações insertas no art. 33 da Lei Antidrogas. (HC 225555/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, j. em 09/12/2012).

Vê-se que a prova amealhada durante a instrução penal é suficiente para o reconhecimento do crime de tráfico de drogas pelos acusados. Com efeito, embora não se possa utilizar elementos do inquérito policial como prova, no caso em questão, como acima aludido em relação ao acusado Leandro, tem-se que a própria versão da acusada em juízo não se revela crível, sendo confirmado por ela própria que ela trazia a bolsa com as drogas, o que termina por conduzir à certeza de culpabilidade.

Outrossim, da análise dos autos, é possível extrair que a ré Maria agia como transportadora eventual, não havendo indícios de que integre organização criminosa, pois para que isto fique manifesto, é necessário que se verifique espontânea vontade de integrar a associação, além de fazer da criminalidade seu meio de vida principal, com habitualidade criminosa, não sendo este o caso de pessoas que são ocasional ou eventualmente cooptadas por tais organizações a praticarem delitos específicos.

Assim, à vista das circunstâncias explanadas, não sendo possível concluir serem os réus integrantes de organização criminosa, não haveria motivos idôneos a afastar a incidência do parágrafo 4º do art. 33 da lei 11.343/2006 ao caso em questão.

Neste sentido é o entendimento jurisprudencial, senão vejamos:

Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que deu parcial provimento ao recurso especial da acusação para afastar a minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. Narra o impetrante, em síntese, que: a) o paciente foi condenado em primeiro grau à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei de Drogas; b) entre a sua prisão em flagrante e o julgamento de recurso de apelação em que se buscava o abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena, cumpriu-se integralmente a pena, tendo sido extinta sua punibilidade; c) sobreveio, então, o ato coator, dando-se sequência à execução da pena privativa de liberdade, redimensionada para 5 anos de reclusão. Busca-se a detração com a alteração do regime de continuação da execução. É o relatório.

Decido. 1. Cabimento do habeas corpus: A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: "O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal." (HC 128693 AgR, Relator (a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) "O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal." (HC 123430, Relator (a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) "(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior." (HC 86367, Relator (a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) No caso concreto, extrai-se dos autos (eDOC 10, p. 74) que o ato coator transitou em julgado em 15.3.2018. Assim, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. 2.

Contudo, no que se refere ao afastamento do redutor previsto no art. 33, § 4º da Lei 11.343/2006, verifico a existência de constrangimento ilegal, passível de conhecimento de plano. No caso concreto, o paciente foi condenado, em primeira instância, pela prática do delito previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais decidiu pela manutenção do redutor com base nos seguintes fundamentos (eDOC 10, pp. 65-66): Em relação à terceira fase de aplicação da pena, pleiteou o Parquet o afastamento da causa de diminuição da pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, ao argumento de que o acusado se dedicava às atividades criminosas. Sem razão o órgão acusador. Compulsando detidamente os autos, verifica-se que embora Jean Carlos tenha sido surpreendido em flagrante após ter sido constatado pelo serviço de inteligência da Polícia Federal o transporte da droga, nada nos autos menciona a respeito de outras atividades ilícitas por ele praticadas. Não há informações nos autos no que tange às investigações anteriormente realizadas, limitando-se os agentes policiais a indicar a respeito apenas da apreensão. Ademais, a meu ver, é dever da acusação trazer para os autos, de forma inequívoca, as informações que têm o condão de incrementar as penas, não havendo, no presente feito, qualquer anotação neste sentido. Assim, não havendo provas suficientes de que o acusado fazia do comércio ilícito seu meio de vida, dedicando-se à atividade criminosa, é possível afirmar que o caso presente se revele como uma ocorrência isolada, o que permite a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º da Lei de Drogas. 2.1. Como se nota, no que atine ao afastamento do redutor, a motivação do Superior Tribunal de Justiça está centrada na expressiva quantidade de droga, superior a 108 kg (cento e oito quilogramas) de cocaína, bem como na constatação da existência de “acordo de recebimento da importância de R\$ 2.000,00 a ser paga por terceiro” para transporte daqueles tabletes, tudo a indicar a dedicação do paciente a atividades criminosas (eDOC 10, pp. 41-42). Não obstante o alto poder lesivo do entorpecente apreendido, não é possível fazer tal ilação sem o suporte de outros elementos fático-probatórios. Segundo a jurisprudência do STF, “[a] quantidade de drogas não poderia, automaticamente, proporcionar o entendimento de que a paciente faria do tráfico seu meio de vida ou integraria uma organização criminosa” (RHC 138.715, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 09.06.2017). Com efeito, a quantidade e a natureza da droga apreendida não são fatores que, isoladamente, impedem a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º da Lei 11.343/2006, notadamente se evidenciada, como no caso dos autos, a mera condição de transportador do paciente, bem como, a partir do que as decisões proferidas permitem observar, o preenchimento dos demais requisitos previstos na minorante. Afirmou o TJMG que “nada nos autos menciona a respeito de outras atividades ilícitas por ele praticadas”. O paciente foi flagrado transportando expressiva quantidade de cocaína, conduta pela qual receberia remuneração. Contudo, à míngua de outros elementos probatórios, não há qualquer indicativo de que integre organização criminosa ou se dedique à traficância habitualmente. A Segunda Turma do STF tem posição firme no sentido de que a condição de “mula” ou a mera alusão ao fato de ter efetuado o transporte de entorpecentes (ainda que entre Estados da Federação), por si só, não impede a incidência da minorante. Para fins de individualização da pena, a singela alusão genérica à importância dos transportadores na estrutura de uma suposta organização criminosa não preenche o figurino exigido pela ordem constitucional. Na mesma linha: “Incidência da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas afastada pelas instâncias de mérito com amparo em mera conjectura ou ilação de que os pacientes integrariam organização criminosa, já que recrutados para transportar drogas ao exterior (mulas do tráfico). Inexistência de base empírica idônea. Constrangimento ilegal configurado. Habeas corpus concedido de ofício. (...) O exercício da função de mula, embora indispensável para o tráfico internacional, não traduz, por si só, adesão, em caráter estável e permanente, à estrutura de organização criminosa, até porque esse recrutamento pode ter por finalidade um único transporte de droga.” (HC 124107, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 04.11.2014, grifei). “PENAL. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS. AFASTAMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE



CONCEDEU O BENEFÍCIO NA FRAÇÃO DE 1/3. PRECEDENTES. 1. A não aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 pressupõe a demonstração pelo juízo sentenciante da existência de um conjunto probatório apto a afastar pelo menos um dos critérios, que são autônomos, descritos no preceito legal: (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não dedicação a atividades criminosas; e (d) não integração à organização criminosa. Nesse juízo, não se pode ignorar que a norma em questão tem a clara finalidade de apenar com menor grau de intensidade quem pratica de modo eventual as condutas descritas no art. 33, caput e § 1º, em contraponto ao agente que faz do crime o seu modo de vida, o qual, evidentemente, não goza do referido benefício (cf. justificativa ao Projeto de Lei 115/2002 apresentada à Comissão de Constituição e Justiça e de Redação). 2. No caso, o Tribunal de apelação afastou a referida minorante com base em argumentos genéricos e teóricos, desprovidos de qualquer elemento contido nos autos, senão no fato de a paciente ter sido condenada pela prática do crime de tráfico transnacional de drogas. Por outro lado, a sentença condenatória afirmou, de forma segura, a inexistência de prova apta a justificar a negativa da causa de diminuição. Precedentes. 3. Ordem parcialmente concedida." (HC 124022, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 24.03.2015, grifei). Dito isso, não visualizo qualquer fundamento hábil a negar a incidência da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 ao paciente. 4. Posto isso, com fulcro no art. 192 do RISTF, não conheço da impetração, mas concedo a ordem de ofício para restabelecer a minorante, devendo a pena do paciente seguir os moldes fixados pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Comunique-se, com urgência, ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais e à Vara de Execuções Criminais da Comarca de Juiz de Fora com cópia do inteiro teor desta decisão. Comunique-se, outrossim, ao Superior Tribunal de Justiça, para ciência. Brasília, 14 de fevereiro de 2020. Ministro Edson Fachin Relator Documento assinado digitalmente. (STF - HC: 181268 MG - MINAS GERAIS 0086299-90.2020.1.00.0000, Relator: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 14/02/2020, Data de Publicação: DJe-035 19/02/2020). (grifos nossos)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. AGENTE NA CONDIÇÃO DE "MULA". PLEITO DE DECOTE DESSA MINORANTE. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. 1. A orientação jurisprudencial desta Casa, na linha do entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal, firmou-se no sentido de que "o fato de o agente haver atuado como 'mula' no transporte da droga não pode - como numa relação, pura e simples, de causa e efeito - levar à conclusão de que ele seria integrante de organização criminosa e, como tal, não seria merecedor da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. A diferenciação deve ser feita, inequivocamente, caso a caso, com base em elementos objetivos e concretos dos autos (REsp n. 1.365.002/MS, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe 11/9/2017). 2. No caso dos autos, o colegiado estadual, respeitando os critérios legais estabelecidos pelo art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 e, ainda, com observância aos pormenores da situação concreta, entendeu que inexistiam nos autos provas que demonstrassem a dedicação do agravado às atividades criminosas ou de que integrasse organização criminosa, embora tenha sido apreendida grande quantidade de entorpecente, qual seja, mais de 32kg (trinta e dois quilos) de maconha. 3. Nesse contexto, para que fosse possível a análise da pretensão recursal de decote dessa minorante, seria imprescindível o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, o que é defeso em âmbito de recurso especial, em virtude do disposto na Súmula n. 7 desta Corte. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 1532159 MT 2019/0190378-6, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 18/02/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2020). (grifos nossos).

PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CRIME QUE DENOTA HABITUALIDADE DELITIVA. EVIDENCIADA AINDA A

PERICULOSIDADE CONCRETA DO PACIENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 1. Trata-se de habeas corpus impetrado em 13 de novembro de 2019, com pedido de liminar, em favor de Pedro Eduardo Costa de Oliveira, em face de decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara de Delitos de Organizações Criminosas da Comarca de Fortaleza/CE. 2. Compulsando os fólios, depreende-se que não assiste razão à defesa, 1) seja porque entendo que a imputação realizada pelos órgãos persecutórios da integração do paciente à organização criminosa é suficiente para comprovar o seu perigo à ordem pública, em razão da habitualidade criminosa ser inerente a esse tipo penal; 2) seja porque entendo estar presente nos autos provas da sua periculosidade concreta; Senão vejamos. 3. A organização criminosa está relacionada à atuação da delinquência estruturada, que visa afrontar diária e habitualmente bens jurídicos fundamentais para o Estado Democrático de Direito. Assim sendo, o indivíduo que decide por livre e espontânea vontade integrar determinada associação, deve ser considerado como uma pessoa que faz da criminalidade seu meio de vida principal. Não estamos aqui a tratar das pessoas que ocasionalmente são cooptadas ou coagidas por essas organizações a praticarem delitos específicos - como, por exemplo, nos casos das 'mulas do tráfico' -, mas sim daquelas que decidiram fazer parte permanentemente da organização, fazendo das práticas criminosas verdadeiras profissões. 4. Ora, a habitualidade criminosa é condição de existência, portanto, condição sine qua non de uma organização criminosa, sendo a jurisprudência uníssona quanto à necessidade de manutenção da prisão preventiva dos réus, cujos autos evidenciam a prática habitual de delitos. Precedentes do STJ. 5. Ainda que se diga que tal indivíduo não detém nenhuma função administrativa, de comando ou de gerência, ele é parte indispensável para o todo harmônico funcionar; e ainda se beneficia, mesmo que indiretamente, do produto oriundo das atividades criminosas diárias e habituais da empresa do crime. (...) 11. HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de habeas corpus, nº 0632586-38.2019.8.06.0000, ACORDAM os desembargadores da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Ceará, por maioria, em CONHECER do habeas corpus impetrado, mas para DENEGAR a ordem, nos termos do voto do relator. Fortaleza, 21 de janeiro de 2020 MÁRIO PARENTE TEÓFILO NETO Relator Designado (TJ-CE - HC: 06325863820198060000 CE 0632586-38.2019.8.06.0000, Relator: MARIO PARENTE TEÓFILO NETO, Data de Julgamento: 21/01/2020, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/01/2020). Grifo Nosso.

Assim, tratando-se de acusados primários (fls. 287/288 e 294), deve ser reconhecida a causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, pois ostentam bons antecedentes e inexistente nos autos comprovação suficiente de que se dediquem a atividade criminosa.

Demais disso, a quantidade de drogas, embora não seja desprezível, é reduzida, autorizando desta feita, o reconhecimento da minorante em patamar máximo. Nesse sentido, o aresto abaixo colacionado.

APELAÇÃO. Tráfico de entorpecentes. Associação para o tráfico de drogas. Recurso ministerial. Pleito de condenação dos apelados como incurso no artigo 35, caput, da Lei n. 11.343/06. Provas suficientes de autoria e materialidade apenas em relação ao tráfico. Mantida a absolvição quanto ao delito previsto no artigo 35, caput, da Lei n. 11.343/06, ante a ausência de provas no que tange à estabilidade e permanência do suposto grupo criminoso. Dosimetria das penas. Confirmado o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/06, no grau máximo. Primariedade, quantidade de droga que não se mostra excessiva e inexistência de elementos que indiquem a dedicação à atividade criminosa ou integração a organização voltada à prática de delitos. Regime inicial aberto e substituição das penas privativas de liberdade por duas restritivas de direitos mantidos nos termos da r. sentença. Evidente erro material na r. sentença em relação às penas de multa. Viável a sua correção. Negado provimento ao recurso, com correção, de ofício, do erro material constante do dispositivo da r. sentença. (TJSP; Apelação 0046355-59.2016.8.26.0050; Relator (a): Leme Garcia; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda

- 32ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 11/07/2017; Data de Registro: 12/07/2017)  
(grifos nossos)

EMENTA HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL E DIREITO PENAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MULA. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. 1. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo quanto a tal recurso de fundamentação vinculada. Salvo hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, inadmissível o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Pertinente à dosimetria da pena, encontra-se a aplicação da causa de diminuição da pena objeto do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. Para verificar a adequação da causa de diminuição ao caso concreto, indispensável observar tanto as condições individuais do agente quanto as da conduta em concreto praticada, de todo incabível a concessão do benefício em caso de reincidência, Maus antecedentes, dedicação a atividades criminosas ou participação em grupo destinado a esse fim. 3. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que 'o exercício da função de mula, embora indispensável para o tráfico internacional, não traduz, por si só, adesão, em caráter estável e permanente, à estrutura de organização criminosa, até porque esse recrutamento pode ter por finalidade um único transporte de droga', porquanto 'descabe afastar a incidência da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 com base em mera conjectura ou ilação de que os réus integrariam organização criminosa' (HC 124.107/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 24.11.2014). 4. Na hipótese, proporcional e razoável a fixação da minorante no patamar de 2/3 (dois terços), considerada a inexistência de circunstância ou fato desabonador ensejador de aplicação de fração menor. Precedentes: HC 132.459/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, votação unânime, DJe 13.02.2017; HC 131.918/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, votação unânime, DJe 02.3.2016; e HC 123.534/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, votação unânime, DJe 10.10.2014. 5. Observados os parâmetros estabelecidos no HC 97.256/RS e no HC 111.840/ES desta Suprema Corte e consideradas a aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, no patamar de 2/3 (dois) terços e "a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis", possível a fixação de regime prisional mais brando - aberto -, e a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. 6. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito, mas com concessão de ofício da ordem, para determinar que o Tribunal Regional Federal da 3ª Região proceda a nova dosimetria da pena, mediante a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, no patamar de 2/3 (dois terços), e reexamine, se o caso, a fixação do regime inicial de cumprimento da pena e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. (STF - HC: 129449 SP - SÃO PAULO 0004774-62.2015.1.00.0000, Relator: Min. ROSA WEBER, Data de Julgamento: 14/03/2017, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-088 28-04-2017). (grifos nossos)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. AGENTE NA CONDIÇÃO DE "MULA". AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE INTEGRA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO INFERIOR AO MÁXIMO ACERTADA. 1. Na hipótese do tráfico ilícito de entorpecentes, é indispensável atentar para o que disciplina o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, segundo o qual o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. 2. No caso concreto, o Tribunal de origem expressamente fundamentou a majoração da pena-base em 2 anos, com fundamento na natureza e

quantidade de entorpecentes - 1920g de "cocaína", nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006 e art. 59 do CP, encontrando-se devidamente justificada e proporcional às especificidades do caso versado. 3. Para a aplicação da minorante do artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, é necessário o preenchimento de quatro requisitos cumulativos, quais sejam, primariedade, bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso em concreto. O legislador, entretanto, não definiu os critérios a serem adotados pelo magistrado para a escolha do percentual de redução da pena. 4. No presente caso, a opção pela fração de 1/6 foi devidamente justificada no fato de o acusado ter contribuído com organização criminosa, agindo na condição de "mula", o que se mostra condizente com os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade e encontra justificativa nas peculiaridades da ação criminosa. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1013343/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 01/08/2017)

Ainda, inexistente qualquer causa excludente de ilicitude ou que isente os réus de pena em relação ao delito de tráfico.

No mais, a ação foi culpável, reprovável, pois os réus eram (e ainda são) ao tempo da conduta imputáveis, tendo consciência da ilicitude de suas ações. Não há, portanto, qualquer causa excludente da culpabilidade.

Isto posto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia para o fim de CONDENAR os réus LEANDRO CESAR CARDOSO e MARIA DO SOCORRO CABRAL BELO, como incurso nas penas do art. 33, § 4º da Lei 11.343/06, ABSOLVENDO-OS, todavia, das imputações relativas ao delito do art. 35, da Lei de Drogas, o que faço com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP.

Apurada a responsabilidade penal, passo a dosar a pena dos réus.

1) Réu Leandro César Cardoso.

Circunstâncias judiciais

Assim, primeiramente, no tocante às circunstâncias judiciais, verifico que o réu agiu com a culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar nesse sentido. Não há nos autos elementos concretos que permitam uma valoração da sua personalidade. O réu não possui maus antecedentes (fls. 287/288). O motivo do delito se constituiu pela obtenção do lucro fácil, que já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito. Nada há, em concreto, que desabone a sua conduta social. As consequências do crime não se mostraram de maior monta. As circunstâncias também não se revelam desfavoráveis ao acusado, lembrando que a quantidade e natureza da droga não apresentam expressão ou magnitude aptas a ensejar a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Diante de tais considerações fixo a pena-base no mínimo legal, em 05 (cinco) anos de reclusão, e 500 dias-multa, no menor valor legal.

Na segunda fase não incidem agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, incide a causa de diminuição de pena, fazendo jus o réu à aplicação do redutor do artigo 33, § 4º da Lei de Drogas, no patamar de 2/3, passando a pena para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 dias-multa. Neste ponto, vale mencionar a manifestação de César Dário Mariano:

Presentes os requisitos previstos na norma a diminuição da pena é obrigatória, não ficando ao alvedrio do Juiz operar a redução ou não. Embora a norma empregue a expressão "as penas poderão ser reduzidas", não se trata de atividade discricionária do Juízo, mas de direito subjetivo do acusado. Aliás, a primariedade e bons antecedentes deverão ser demonstrados pelo acusado, ao passo que caberá ao Ministério Público o ônus de provar que o réu se dedica à atividade criminosa ou que pertence à organização criminosa. Não cabe ao réu a prova de fatos negativos, mas a quem alega, no caso, o Ministério Público.

(...) Dedicar-se a atividades criminosas pressupõe reiteração de condutas tipificadas como crime, ou seja, habitualidade no cometimento de delitos. Tal

circunstância poderá ser demonstrada por meio de folhas de antecedentes criminais, certidões cartorárias, cópias de outros processos, testemunhas, ou seja, qualquer meio hábil a provar a vida criminosa do acusado. Como a norma não diz qual espécie de atividade criminosa poderá ser qualquer uma, desde que, obviamente, não se trate de delitos culposos, que pressupõem ausência de vontade. A norma visa a impedir a redução da pena para aquele que de forma habitual e deliberada pratica qualquer